

1501098-75.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... e tinham em depósito, para fins de tráfico, 5,18 gramas de cocaína e 2,64 gramas de crack, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Notificado (fls. 166), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 170/171.

A denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501098-75.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501098-75.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2275558/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 20724185 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 6933/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2275558 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 6933/21/050 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

WELLINGTON CARLOS DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

WELLINGTON CARLOS DE SOUZA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque, em conjunto com a corré Gisele Aparecida da Silva, no dia 07 de outubro de 2.021, por volta das 13h50, na rua Presidente Kennedy, quadra 01, nesta cidade, traziam consigo, transportavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 5,18 gramas de cocaína e 2,64 gramas de crack, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, associaram-se para a prática do crime

de tráfico de drogas.

Notificado (fls. 166), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 170/171. A denúncia foi recebida por despacho datado de 14 de dezembro de 2.021 (fls. 173/176).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 217 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 221/228).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 232/274, alegando que: 1)- na fase policial, os policiais disseram que o acusado estava deitado quando abordado e, perto dele, estavam as drogas e o dinheiro, ao passo que, em juízo, afirmaram que todas as pessoas que estavam no local foram retiradas até uma avenida com seus pertences e revistados; 2)- o fato não é de pequena relevância pois, no local, vivem dezenas de pessoas e ali é frequentado por usuários e não tem divisórias, podendo o entorpecente pertencer a qualquer um; 3)- nada garante que a corré identificou o réu como seu fornecedor de drogas, pois ela e Jayme não foram ouvidos em juízo; 4)- tendo o réu quantidade ínfima de droga em seu poder, não pode ser considerado fornecedor de entorpecentes de Gisele e de diversos pontos da cidade; 5)- as drogas encontradas com Gisele eram distintas daquelas apreendidas em poder do réu; 6)- se Gisele trabalhasse vendendo drogas para o acusado, teria-o identificado pelas tatuagens dele, inclusive do seu rosto; 7)- nos documentos da polícia civil, fls. 43/48 e 72/73, não consta que o apelido do réu é Nikito; 8)- os depoimentos dos policiais não são suficientes para a condenação; 9)- o crime de associação para o tráfico não se caracterizou; 10)- eventualmente, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 21 e pelo laudo pericial de fls. 111/115 (uma porção de crack com peso de 0,19 gramas; treze porções de crack com peso de 2,52 gramas; e dezoito porções de cocaína com peso de 5,18 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Interrogado na polícia, ele declarou que não trabalha e é morador de rua. Vive em uma cabana de pano, debaixo do viaduto do rio Bauru, altura da rua Araújo Leite. Não é usuário de drogas, apenas consome bebida alcoólica. Sustenta seu vício pedindo dinheiro nos semáforos e também recebe ajuda de desconhecidos. Convive com outra moradora de rua, que está grávida. Sua companheira é usuária de crack e álcool. Estava do lado direito do rio, debaixo da ponte, quando policiais chegaram. Estava bebendo pinga e deitado no colchão. Portava cerca de R\$ 2.200,00, parte derivada de "fundo assistencial" do governo federal, parte advinda da venda de um telefone celular e parte fruto de economias. Debaixo do pontilhão, moram dezenove pessoas. Dezesete delas usam drogas e, por isso, estava com seu dinheiro. Nada de ilícito foi encontrado consigo. Não viu a localização das drogas. Não tem envolvimento com tráfico e nenhum morador do local tem (fls. 10).

Interrogada na polícia, a corré Gisele declarou ser moradora de rua e ficar num barraco, situado debaixo da ponte que liga a região central da cidade com o bairro Bela Vista, perto do antigo INSS. Tem quatro filhos, todos em abrigo, e trabalha como recicladora de materiais. É usuária de crack há mais de dez anos. Sustenta seu vício catando recicláveis, pedindo dinheiro no farol e até já fez programas sexuais. Parou com tal atividade porque se casou. Juntou dinheiro da venda de recicláveis e adquiriu 18 porções de crack, ganhando duas de brinde. Adquiriu-as de "Nikito", que fica na avenida Nuno de Assis, traficando. Com as drogas em mãos, foi até o pontilhão situado perto do fórum, onde aguardava seu marido. Ele havia ido buscar cigarros. Ia consumir o entorpecente. Ali chegou um indivíduo e disse que

queria uma pedra para "fortalecer". O indivíduo estava acompanhado de outro. Resolveu-lhe fornecer uma pedra de crack pelo preço de 10 reais. Quando estava entregando a droga, policiais militares chegaram. O indivíduo jogou a porção no chão. Tinha consigo um porta moedas, dentro do qual havia mais pedras de crack, salvo engano, quatorze. Também tinha sessenta reais, no máximo. Estava no local há apenas dez minutos. Já havia consumido umas quatro pedras de crack. Houvera consumido drogas em outro local. Resolveu colaborar com os policiais e lhes disse que poderia levá-los até onde "Nikito" estava escondido com mais drogas. Indicou aos policiais onde "Nikito" estava e eles o localizaram debaixo de uma ponte na avenida Nuno de Assis (fls. 12).

Em juízo, a testemunha Marcelo Wanderley Barreira, policial militar, afirmou que, quando em patrulhamento, recebeu denúncia informando que, embaixo do viaduto da Avenida Nuno de Assis, havia uma mulher de pele negra e com roupa de estampa de onça e calça preta, realizando tráfico. A denúncia também dava conta de que ela pegava drogas de um indivíduo de alcunha "Nikito", o qual agenciava o tráfico no local. Dirigiu-se ao ponto indicado e visualizou a mulher em questão, bem como, perto dela, um rapaz. Ao ver a viatura, este dispensou algo. Constatou tratar-se de uma pedra de crack. Os dois foram separados. Indagado, o rapaz disse que havia adquirido a pedra da ré Gisele, por dez reais. Na mão dela, o policial Ortiz encontrou um porta moedas, no qual estavam contidas outras dez pedras, iguais àquela achada em poder do rapaz. Indagada, ela confessou a traficância e explicou que pegava as drogas com "Nikito". A ré portava dinheiro e admitiu que o numerário era produto de tráfico. Os policiais a indagaram onde estaria o fornecedor. Ela os conduziu a um local situado embaixo da ponte, perto da rua Araújo Leite e rio Bauru. Pediu apoio a outra viatura. Do lado esquerdo da ponte, havia vários usuários e, do lado direito, o acusado estava deitado num colchão com a namorada. Os dois foram revistados. Os policiais pediram que todos saíssem debaixo do viaduto e pegassem seus pertences. Alguns subiram com mochila. Na sacola de papelão do réu, havia seus pertences pessoais e pares de meia. Num dos pares de meia, havia diversas moedas, bem como notas organizadas em elástico. Em outro par de meia, havia dezoito pinos de cocaína. Indagado sobre a droga, o réu dava risada e dizia que dela não sabia dela. Ele também afirmou que adquiriu o dinheiro ao olhar carros na área central. Havia mil cento e sessenta reais em cédulas. O restante era moedas. Com Gisele, estavam treze pedras de crack. Foi ela quem indicou "Nikito" e levou os policiais até onde ele estava. O acusado sempre estava muito bem vestido para ser morador de rua. Ele aparentava tomar banho. No colchão, foram encontrados vários sacolés usados para embalar entorpecente. Não acha que o réu morava ali, pois ele estava sempre arrumado e de banho tomado. Gisele disse que, às vezes, o acusado dormia no local. Ela não contou exatamente por quanto tempo o réu lhe fornecia drogas. Mas já eram alguns meses, pois ela estava sem dinheiro e precisava sobreviver. Gisele também explicou que, às vezes, o réu lhe levava droga e, outras vezes, ela lhe levava o dinheiro e pegava mais entorpecente. O acusado negou tudo o que era perguntado. Havia cento e dez reais em moedas diversas. As cédulas eram também diversas. Os sacolés foram apreendidos e levados para a delegacia. Um usuário foi quem fez a denúncia, desde logo informando sobre "Nikito". Os policiais ouviam falar de "Nikito", mas não sabiam tratar-se de Wellington. Já o conhecia pelo seu nome, pois já o houvera abordado na área central, na praça Rui Barbosa e na rodoviária. Segundo denúncias de usuários, ele era o responsável por abastecer a praça Rui Barbosa. Os pinos estavam em meias, as quais, por suas vezes, estavam dentro da sacola de papelão. Já havia abordado Gisele tanto ali quanto mais para frente, mas sempre na linha. Abordava-a com dinheiro, mas não com drogas. Na data do fato, chegou por trás e ela não percebeu a aproximação dos policiais. Já foram presas várias pessoas embaixo do pontilhão, por tráfico. Embaixo do viaduto do cruzamento da Avenida Nuno de Assis com rua Araújo Leite, moram usuários e catadores de recicláveis. Na data do fato, todos foram revistados. Ali, havia uma outra pessoa que não tinha documento. Ela foi conduzida ao plantão para ser identificada e acabou sendo liberada. Tratava-se de um travesti.

A testemunha Rodrigo Fabiano Ortiz, também policial militar, disse que, durante patrulhamento, foi abordado por um transeunte, o qual o informou de que, debaixo do

viaduto que vem da Vila Falcão, havia uma moça de pele negra e roupa com estampa de onça praticando tráfico. Foi até o local e viu a acusada Gisele e, perto dela, um rapaz agachado. Este fez gesto de jogar algo no chão. O cabo Marcelo verificou tratar-se de uma pedra de crack. Abordou a acusada. Em poder dela, havia um porta moedas contendo treze pedras de crack. Na cintura, Gisele tinha setenta e quatro reais. Indagada, ela disse que vendia as drogas para sustentar o vício e comprar alimentos, bem como que trabalhava para um rapaz chamado "Nikito" e que recebia uma porcentagem das vendas. A ré conduziu os policiais ao local onde "Nikito" estava, situado a algumas quadras de distância, na mesma Avenida Nuno de Assis. Com apoio de outra viatura, seguiu até o lugar indicado, viaduto da rua Araújo Leite, próximo ao posto Shell. Ali havia várias pessoas, moradoras de rua. Gisele indicou quem era "Nikito". Conhecia-o, mas por outro nome. Os policiais ordenaram que as pessoas ali presentes ficassem em pé para serem revistadas. Foi formada uma fila em frente ao viaduto e várias pessoas foram revistadas, bem como identificadas por documentos. Em seguida, elas foram liberadas. O réu portava uma sacola de papelão contendo pares de meia e produtos de higiene e de perfumaria. Indagado, ele confirmou que aqueles itens lhe pertenciam. Em revista na sacola, foi achada uma peça de meia contendo dezoito pinos de cocaína. Em outra meia, havia cento e dez reais em moedas. Em mais uma meia, existiam várias notas de dinheiro (cinco, dez, cinquenta e cem reais), que totalizavam mil quinhentos e sessenta reais. Indagado novamente, o acusado admitiu que o dinheiro e os itens de perfumaria eram seus mas, sobre a droga, negou a propriedade e deu risada. Revistou o pessoal que estava do outro lado do viaduto e nada de ilícito localizou. Um outro rapaz, homossexual, foi conduzido, pois dizia que era parente da namorada do réu. Quando abordado, este estava num colchão, ao lado de uma moça. O colchão foi revistado e nele havia vários saquinhos plásticos, comumente usados para embalar drogas. Já conhecia o réu, em razão de uma apuração de roubo. Naquela oportunidade, ele chegou a ser reconhecido como autor de roubo por uma vítima. Porém, na delegacia, houve um erro no procedimento, pois o réu passou em frente à vítima, e ela não quis mais reconhecê-lo, por temer que ele lhe fizesse alguma coisa. A ré Gisele declarou que era o acusado Wellington quem lhe fornecia entorpecente. O indivíduo que ali estava comprando droga disse o mesmo e acrescentou que o réu comandava o tráfico e distribuía droga no local e no viaduto da rua Treze de maio. Quando da apuração do roubo, o réu foi encontrado na rodoviária nas mesmas circunstâncias, ou seja, com colchão no chão e pessoas em volta. O usuário abordado com Gisele, de nome Jayme, disse aos policiais: "vocês vão levar ela, mas quem comanda aqui, quem gerencia é o cara lá". Gisele e Jayme disseram que já fazia algum tempo que o acusado gerenciava o tráfico, mas não precisaram dias e meses. O réu estava em um colchão, ao lado de uma moça. Ao lado deles, havia um outro indivíduo com um cachorro pitbull, que aparentava fazer a segurança. O acusado já tinha sido abordado na Praça Rui Barbosa e não aparentava ser morador de rua, pois estava sempre limpo. Aparentemente, ele estava sempre na rua. As abordagens anteriores ao réu - na praça Rui Barbosa e quando do roubo, na rodoviária - ocorreram há menos de um ano, pouco tempo antes de ele ser preso. Os policiais escutam várias denúncias e começam a apurar. Havia várias pessoas em volta do acusado. Tem pessoal que não consegue entrar no albergue noturno e fica na rua. Quando todos os abordados subiram para a avenida a fim de serem revistados, a ré Gisele confirmou que o réu era a pessoa de apelido "Nikito". Antes de ele ser abordado, Gisele e o usuário Jayme disseram que "Nikito" era moreno e forte, mas sem maiores indicações específicas. Os dois estavam com medo e foram mais vagos. A ré Gisele já foi abordada várias vezes no mesmo trecho. Encontrava-se dinheiro com ela, mas não droga. Na data do fato, o marido dela veio correndo e disse que ela houvera feito uma loucura, que não deveria vender ali porque ali era "sujo". Aparentemente, ela estava em situação de rua. Interrogado em juízo, o réu disse que o dinheiro, mil e quinhentos reais, era seu. Juntou-o com sua esposa para alugarem uma casa na Vila Seabra. Não conhece a ré Gisele. Mora na Vila Falcão. Muitas vezes, os mesmos policiais o abordavam. Isto porque, há muito tempo atrás, tinha envolvimento com droga e morava debaixo daquele pontilhão. Recebia muita ajuda do Centro Pop, situado em frente ao pontilhão. Quando voltou para a casa de sua família, continuou frequentando a assistente

social do Centro Pop. Na data do fato, pegou sua mulher na rodoviária e foi até a ponte, onde passou a conversar com moradores. Os policiais chegaram e os abordaram. Estava com sua mulher e seu cachorro. Os policiais mandaram que subissem para a avenida. No seu grupo, havia cerca de nove pessoas. Havia outras, do outro lado. Os policiais juntaram alguns pertences que ali havia e iam perguntando de quem era. Disse-lhes que uma sacola era sua. Não pode dizer se os policiais colocaram a droga dentro dela ou se foi "alguém deles lá", pois estavam em muitas pessoas. Afirmou ao sargento que o dinheiro lhe pertencia. Ele não havia falado de droga até então. O sargento foi do outro lado da ponte e pegou os outros moradores de rua, bem como trouxe um travesti, dizendo que o conduziria à delegacia por ter encontrado sacos plásticos em poder dele. Ele e o travesti foram colocados na viatura. O policial disse que o levaria por não ter demonstrado a origem do dinheiro. Na delegacia, foi-lhe falado que estava sendo acusado de tráfico. Seu pai tem uma firma de serralheira e, muitas vezes, ajudava-o. O dinheiro é parte desse seu trabalho e também fruto de seu auxílio. Estava juntando dinheiro porque queria tirar carteira de motorista pela Autoescola Bauru. Mas, com a pandemia, ficou com o dinheiro. Tinha um relacionamento recente com essa moça da cidade de São Pedro e iriam alugar uma casa, para que ficassem mais perto. Não tinha moedas, apenas cédulas. Mora na Vila Falcão desde aquela época, com seus pais. Residia junto com os pais, a irmã e um sobrinho.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa que sustentam o contrário.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, os quais foram conduzidos até o acusado por pessoa (corrê Gisele) em poder da qual foram encontrados R\$ 74,00 e treze pedras de crack e que houvera acabado de negociar uma décima quarta com indivíduo de nome Jayme, flagrado ao lado dela. Outrossim, também de acordo com os policiais, o réu portava o valor total de R\$ 1.670,00 (conforme ainda demonstrado no auto de apreensão de fls. 21), a maior parte em cédulas diversas e menor parte em moedas, bem como tinha guardado, em uma sacola de papelão, dezoito porções de cocaína. Por fim, os milicianos disseram que, no colchão no qual ele estava deitado com a namorada ou companheira, havia sacos plásticos (segundo o auto de apreensão de fls. 21, cem sacos plásticos).

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

A tudo some-se que, mesmo tendo o réu dito que estava na companhia de sua namorada ou companheira, sequer a arrolou como testemunha, a fim de que se pudesse aferir a seriedade e verossimilhança de sua versão.

Não vinga a tese da defesa, no sentido de que a droga cuja propriedade/posse foi atribuída pelos policiais ao réu poderia pertencer a qualquer outra pessoa presente no local.

Não é correto o argumento de que, ao contrário do afirmado quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, os policiais disseram em juízo que os indivíduos encontrados debaixo do viaduto foram conduzidos até uma avenida com seus pertences e revistados.

Na verdade, o que foi afirmado pelos agentes públicos na polícia e em juízo não divergem, bastando apenas a correta interpretação mediante a consideração de que os depoimentos foram colhidos em circunstâncias e para finalidades distintas.

Assim é que, em juízo, apenas se especificou um pouco mais como se deram as revistas das pessoas presentes, dentre as quais o réu.

O que não quer dizer que, ao chegarem no local, os policiais não perceberam que a sacola na qual contido o entorpecente apreendido estava junto do acusado.

Ademais, os policiais afirmaram que o dinheiro estava na mesma sacola.

Observado que o próprio acusado admitiu a propriedade e posse do numerário, não há dúvida de que a sacola em questão e, conseqüentemente, as porções de cocaína, pertenciam-lhe.

Reforça tal conclusão o fato de que, no colchão em que ele estava deitado com a namorada ou companheira, foram encontrados cem sacos plásticos comumente usados para embalar drogas.

A ninguém é dado negar que nenhum indivíduo porta tal quantidade de "sacolé" com boas intenções, em plena via pública, deitado num colchão e em local conhecido como ponto de tráfico.

A circunstância em questão permite ainda refutar outra tese da defesa, segundo a qual, sendo a droga encontrada em poder de Gisele distinta daquela apreendida na posse do réu, não haveria vínculo entre eles.

Embora a premissa seja verdadeira (Gisele portava crack, ao passo que o réu tinha consigo microtubos de cocaína - fls. 21), a conclusão não o é, pois não pode ser olvidada a presença de cem sacos plásticos no colchão onde o acusado estava deitado, sendo próprio lembrar, aqui, que tal material é comumente utilizado para embalagem de pedras de crack.

Outrossim, embora nem Gisele e nem Jayme tenham sido ouvidos em juízo, a narrativa de que eles indicaram o réu como sendo quem fornecia drogas à primeira ganha verossimilhança na medida em que, como visto, ela portava drogas e dinheiro e havia acabado de vender uma porção de crack ao segundo, ao passo que, em poder do terceiro, foram encontrados não apenas dezoito microtubos de cocaína como também cem sacos plásticos e elevada quantia em dinheiro (R\$ 1.670,00).

Dito de outro modo, os policiais, logo após a prisão de Gisele em flagrante delito de comércio de drogas, não teriam o dom da adivinhação para se dirigir a outro local, embora próximo, a fim de aleatoriamente prender outro indivíduo possuidor daqueles itens, igualmente relacionados ao tráfico.

Noutro aspecto, não deve haver dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico. Insista-se que ele foi detido em local conhecido pela prática do comércio espúrio, após ter sido apontado por Gisele e Jayme como fornecedor de droga, na posse de dezoito microtubos de cocaína, cem sacos plásticos e R\$ 1.670,00.

Saliente-se que a origem lícita de tal numerário sequer foi demonstrada.

Outrossim, o réu declarou, em solo policial, que portava cerca de R\$ 2.200,00, parte derivada de "fundo assistencial" do governo federal, parte advinda da venda de um telefone celular e parte fruto de economias.

Já em juízo, a versão foi outra, ou seja: o dinheiro apreendido, R\$ 1.500,00, derivou de seu trabalho de ajudante ao pai, que é serralheiro, e também de auxílio pago pelo Governo.

Como quer que seja, as alegações sobre a origem do valor, formuladas tanto na polícia como em juízo, poderiam ter sido facilmente demonstradas.

Afinal, o pai não se recusaria a vir depor em juízo para comprovar fato de interesse de um filho acusado injustamente de prática de tráfico.

Da mesma forma, se houve venda de celular, bastaria que se buscasse trazer o depoimento do comprador.

E, ainda, o recebimento de benefício do governo poderia ter sido comprovado por meio de documentos.

A inércia da defesa, no ponto em questão, é sintomática.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a guarde e a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, a condenação do réu por crime de tráfico é medida de justiça.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, no entanto, a absolvição se impõe.

Isto porque não se demonstrou, de modo estreme de dúvidas, circunstância capaz de demonstrar a existência de "ânimo associativo" entre os envolvidos, nem que o vínculo entre eles era dotado de permanência e estabilidade.

Embora os policiais tenham colhido informações, junto à Gisele e Jayme, bem como a usuários de drogas, no sentido de que o réu era responsável por distribuir droga e gerenciar o tráfico na região central da cidade, não há outros elementos a conferir verossimilhança à informação.

Ao contrário, segundo o policial Rodrigo Ortiz, Jayme lhe disse: "você vão levar ela, mas quem comanda aqui, quem gerencia é o cara lá".

Como se nota, no momento da abordagem de Jayme e Gisele, buscou-se indicar à polícia que o maior responsável pelo tráfico era o acusado, o que foi feito com o intuito de tirar da polícia o foco sobre Gisele, visando, certamente, que os policiais fossem à cata de Wellington e que a liberassem.

Assim considerado o exagero, não é possível conferir a seriedade necessária às afirmações informais feitas por Jayme e Gisele aos policiais, ao menos no ponto em que mencionam que Wellington já vinha, há razoável período de tempo, gerenciando o tráfico na região central da cidade, e fornecendo drogas a Gisele por período prolongado de tempo.

Por outro lado, as afirmações colhidas pelos policiais junto a usuários igualmente não podem embasar conclusão de que o réu atuava de forma reiterada no fornecimento de drogas a outros traficantes no varejo do centro da cidade, inclusive Gisele.

Isto porque se cuida de dados relatados à polícia de forma anônima.

A notícia anônima é inservível a decreto condenatório, na medida em que o informante, justamente em razão do anonimato, não responde por falsa incriminação e pode vir a fazê-la buscando prejudicar um desafeto.

Enfim, não é possível descartar que a reunião dos acusados para a prática criminosa tenha se dado de forma isolada.

Nessas circunstâncias, não se caracteriza o delito de associação para o tráfico, que exige mais do que a simples coautoria.

Nesse sentido:

"Com relação ao crime de associação (art. 35), em que pese o inconformismo ministerial, tal delito não restou minimamente demonstrado pela prova dos autos, como judiciosamente analisado pela douta Magistrada sentenciante. A conduta descrita no art. 35 da Lei n. 11.343/06 vem representada pelo verbo 'associar', que significa agregar-se, unir-se. Essa associação, no entanto, deve observar um mínimo de estabilidade. Não se confunde, assim, com o mero concurso de agentes. O crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os agentes. E sem a prova efetiva de uma verdadeira associação permanente e duradoura voltada à prática do tráfico ilícito de drogas, não há como sustentar um decreto condenatório. Tal qual o crime de quadrilha ou bando, a associação para a traficância exige elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. O de associação em especial para o crime de tráfico. É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação. Porém, inadmissível que

toda e qualquer comparsaria para a prática delituosa, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância." (TJSP, Apelação Criminal n. 0001922-45;2009.8.26.0363, rel. Newton Neves, j. 1º/02/2011).

Passa-se à aplicação da pena,

O réu não tem antecedentes criminais (fls. 86/87).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11343/2006.

Destaque-se que a quantidade de droga apreendida não era das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa. A quantidade de dinheiro, embora razoavelmente elevada, não o era a tal ponto de permitir conclusão de se tratar, aqui, de agente contumaz na realização da mercancia espúria.

Ademais, ainda que pareça suspeita de que o réu poderia ser distribuidor de drogas em área central da cidade, o fato não foi devidamente demonstrado, conforme fundamentos expostos para afastar o crime de associação para o tráfico.

Acrescente-se, de resto, que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida.

Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena. Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado. Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 - A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de 'atividade criminosa'. 2 - Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 - Recurso provido, para reduzir a pena em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. 1.085.039/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-62.2013.8.26.0071).

Afigura-se justo deferir a diminuição no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas não foram das mais elevadas. Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não

constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso.

Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, quantidades não exorbitantes de droga e dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto para o delito de tráfico.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro não serem das mais elevadas, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para: 1)- condenar o réu Wellington Carlos de Souza como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei n. 11343/2006, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução e, 2)- absolver o réu Wellington Carlos de Souza da acusação do cometimento do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Em razão do regime prisional imposto, expeça-se alvará de soltura.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

P.R.I.

Bauru, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA